

1500742-76.2019.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... comum o envolvimento de consumidores de drogas com o tráfico.

Comprovada a autoria do crime de tráfico, assinala-se que a materialidade igualmente está bem demonstrada: o réu, abordado e surpreendido na posse de drogas destinadas ao tráfico, foi preso em flagrante delito (Auto de Prisão em Flagrante Delito a fls. 01) e a respeito da conduta foi lavrado Boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, .

Centro - CEP 12020-070, Taubaté-SP

Fone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1500742-76.2019.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500742-76.2019.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Réu

Justiça Pública

Jhonatas Luiz da Silva Pereira

Vistos.

Jhonatas Luiz da Silva Pereira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque em 30 de junho de 2019, por volta das 23h41min, na Avenida José Bonifácio Moreira, 1149, bairro Belém, nesta cidade e comarca de Taubaté, trazia consigo, para fins de tráfico, 66 porções de cocaína sob a forma de crack, droga que causa dependência física e psíquica, com peso total bruto de 61,16g, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Descreve a denúncia que o réu adquiriu as drogas mencionadas e passou a vendê-las no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico. Policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando se depararam com o réu e outro rapaz e, por lhes parecer suspeita a atitude do réu, resolveram abordá-los. Ao perceber que seria abordado, o réu jogou ao solo um saco de papel, conduta que foi presenciada pelos policiais. Em revista pessoal, nada foi encontrado com o outro rapaz, o qual disse que estava no local para comprar drogas. Já com o réu, no bolso da blusa que ele trajava, os policiais encontraram uma porção média de crack, lâminas de gilete e a quantia de R\$ 100,00 em dinheiro. No chão, próximo ao local onde o réu estava, os policiais recolheram o saco de papel dispensado por ele e constataram que no seu interior havia 65 porções de crack embaladas para a venda. O réu admitiu, informalmente, que estava no local praticando o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 88/89).

Recebida a denúncia, em 10 de julho de 2019 (fls. 93/94), antes mesmo de ser citado (fls. 134) o réu apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 125/130).

Confirmada a liminar antes concedida (fls. 81/83), com concessão da ordem no julgamento do Habeas Corpus nº 2146692-70.2019.8.26.000 pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao réu foi concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares (fls. 163).

O processo foi saneado, com rejeição da matéria preliminar arguida na defesa preliminar (fls. 141/142), e realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que se procedeu à inquirição dos policiais militares Carlos Maciel de Souza e Bruno Ramon Lopes dos Santos, testemunhas do rol acusatório, comuns à defesa, e da testemunha exclusiva da defesa, Rosângela Cristina da Silva (fls. 169/170). Ante a ausência da testemunha Elias de Oliveira Guimarães, homologou-se a desistência de sua oitiva pela acusação, passando a ser testemunha exclusiva da defesa, a qual insistiu na sua oitiva, sendo designada nova data para o desiderato, que foi prejudicado ante a sua ausência (fls. 189).

Tendo em vista a instituição do Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau pelo Provimento CSM nº 2549/2020, com vigência a partir de 25/03/2020, e o impedimento de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns por força da pandemia de Covid-19, determinou-se que se aguardasse o restabelecimento do expediente ordinário presencial pelo prazo de noventa dias (fls. 197).

Autorizado pelo Provimento CSM nº 2564/2020 o retorno gradativo dos serviços presenciais nos órgãos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, realizou-se audiência de instrução em continuação por meio de teleconferência, quando foi inquirida a testemunha da defesa, Elias de Oliveira Guimarães. Ao final realizou-se o interrogatório do réu (fls. 242).

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, pois provadas materialidade e autoria do delito, não obstante a negativa do réu, a qual restou isolada frente aos depoimentos dos policiais, que não comportam reservas. No que tange à aplicação da pena postulou: a fixação da pena-base acima do mínimo legal em vista da maior potencialidade lesiva do crack; nada seja considerado na segunda fase de dosimetria; não seja aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em razão da quantidade de drogas apreendida e por haver evidências da dedicação do réu a atividades criminosas, ou, caso se entenda cabível a redução, que não ocorra em patamar máximo. Pleiteou, por fim, a fixação do regime inicial fechado de cumprimento da privação de liberdade, que esta não seja substituída por restritiva de direitos e, ainda, o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, por não comprovada sua origem lícita.

Já a Defesa do réu pugnou por absolvição em razão da ausência de provas de autoria do crime de tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a de posse de drogas para uso próprio, pois a porção de entorpecente encontrada na posse do réu era destinada ao seu consumo. Afirmou que o réu não tem envolvimento com atividades criminosas e trabalha como ajudante geral, fatores que, na hipótese de condenação, possibilitam o arbitramento das penas nos mínimos legais, a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao tempo dos fatos e, de acordo com o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a redução da pena no patamar máximo, cominando-se regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, com reconhecimento da possibilidade de apelar em liberdade (fls. 243/251).

É o relatório.
Decido.

O réu é acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Permaneceu em silêncio ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 09), e em juízo admitiu apenas a propriedade de uma pedra de crack apreendida diretamente em sua posse, negando lhe pertencessem outras pedras, que estavam em uma sacola, a qual, segundo alegou, teria sido encontrada pelos policiais cerca de cem metros adiante do local em que se encontrava, havendo se surpreendido com a acusação de posse da droga acondicionada em seu interior. Afirmou, ainda, que a droga que estava consigo seria destinada ao seu consumo, pois é usuário de crack, negando intenção de tráfico. Justificou-se dizendo que estava no local a caminho da casa de sua namorada; não conhecia Elias, estando juntos apenas porque o encontrou na rua e pediu que lhe fizesse companhia; as lâminas que estavam em seu poder são usadas para cortar as pedras de crack, para que possa usá-las, e o dinheiro que portava era proveniente de seu trabalho de serralheiro, que exerce mediante registro e pelo qual auferia cerca de R\$ 1.200,00 ou R\$ 1.300,00 mensais. Negou, por fim, ter afirmado aos policiais que estava no local vendendo drogas.

Ocorre, todavia, que os policiais militares que o abordaram, Carlos Maciel de Souza e Bruno Ramon Lopes dos Santos, apresentaram narrativa uníssona que contraria o quanto alegado pelo réu.

Em depoimentos uniformes, tanto entre si, bem como em relação às duas oportunidades em que inquiridos, os policiais militares descreveram que durante patrulhamento, em local conhecido como ponto de venda de drogas, se depararam com o réu e a testemunha Elias caminhando pela via pública. Decidiram abordá-los e enquanto o faziam visualizaram que o réu dispensou no chão uma sacola de papel, na qual, quando averiguada, constataram que havia 65 pedras de crack embaladas individualmente. Além disso, em revista pessoal, foi encontrada na blusa do réu uma porção de entorpecente que aparentava ser crack, três lâminas de barbear e R\$ 100,00 em dinheiro, em notas de R\$ 20,00. Indagado, o réu confessou aos policiais a prática do tráfico de entorpecentes, cuja compra teria efetivado na cidade de Caçapava, por R\$ 500,00, para posterior revenda no bairro. Nada foi encontrado com Elias, tendo ele afirmado ser usuário de crack e ter ido ao local para adquirir entorpecentes.

Os policiais militares foram claros quanto à posse, pelo réu, não só da porção de entorpecente que estava diretamente em seu poder - o que ele admitiu em juízo -, mas também dos demais entorpecentes que estavam em uma sacola, que ele foi visualizado dispensando ao início da abordagem pela guarnição policial.

Nesse contexto resta isolada - e perde a credibilidade - a versão de Elias de Oliveira Guimarães, em juízo, de que nem ele, nem o réu, portavam drogas, já que o próprio réu admitiu o fato, ainda que não integralmente.

Ainda que em juízo Elias tenha corroborado a narrativa do réu de que este estava indo à casa da namorada quando ambos se encontraram na rua e foram abordados, contrariou a alegação do réu de que não se conheciam anteriormente. Mesmo que essa circunstância não seja relevante para o desfecho da ação, demonstra que ambos eram, sim, conhecidos anteriormente, o que pode ter induzido Elias a descrever os fatos de forma pouco diversa de como efetivamente ocorreram, a exemplo de sua declaração de que os policiais os revistaram e nada encontraram, mas, "do nada", "vieram com droga na mão".

Não se olvide que Elias havia afirmado à autoridade policial que, quando dos fatos, ao passar na via, perguntou ao réu onde conseguiria crack para consumir. De acordo com seu relato, o réu disse ter percebido que Elias estava "na abstinência" e que arrumaria a droga para ele, pedindo que o acompanhasse até a esquina, ocasião em que foram abordados pelos policiais.

Portanto, embora possam ser verdadeiras as assertivas de Elias de que não

presenciou o réu dispensar algo ao solo e de que não ouviu o diálogo entre o réu e os policiais, percebe-se que em juízo buscou alterar a narrativa em solo policial indicativa de que o réu forneceria drogas a ele, por ser usuário de crack e “estar em abstinência”.

Não remanescem dúvidas de que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas: foi abordado quando estava em conhecido ponto de tráfico, em poder de sessenta e seis pedras de crack embaladas individualmente, na posse direta de uma e mantendo as demais em sacola que foi visto dispensando ao chão quando da abordagem policial, todas condutas características de quem está no local para vender drogas a terceiros.

Embora em juízo o réu tenha negado esse fato, os policiais afirmaram que durante a abordagem, informalmente, o réu confessou que estava no local exercendo a traficância, inclusive relatando que havia adquirido as drogas em Caçapava, pelo valor de R\$ 500,00, para posterior revenda nesta cidade. Tamanha riqueza de detalhes não seria referida pelo PM Carlos Maciel se não lhe houvesse sido apontada pelo próprio réu.

Os policiais e o réu não se conheciam anteriormente à abordagem em questão, não se havendo apontado, sequer comprovado, causa de eventual suspeição, podendo a prova acusatória ser recebida sem reservas.

Conquanto o réu tenha referido que o dinheiro que portava era proveniente da profissão de serralheiro - atividade que sua mãe, Rosângela Cristina da Silva, confirmou que o réu exercia com o pai - não comprovou, embora com oportunidade, a origem lícita do numerário, o que poderia providenciar por meio de documentos, já que apontou ser registrado. Conclui-se que o dinheiro - em notas miúdas, conforme descrito pelos policiais - é produto da narcotraficância.

Não se olvide que o exercício de atividade lícita não é incompatível com a prática da narcotraficância; pelo contrário, muitas vezes serve-lhe de facilitador, até pelo contato com potenciais consumidores das drogas.

Resta assinalar a inviabilidade de desclassificar-se a conduta para a de posse de drogas para uso próprio, porquanto desatendidos os critérios estabelecidos no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, o qual preconiza que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Sobre tais circunstâncias observa-se: o réu estava na posse de quase 22g de cocaína, distribuídos em sessenta e seis pedras de crack, quantidade, por si só, indicativa da destinação ao tráfico; ainda, com o réu havia lâminas destinadas à partição do entorpecente em porções menores, e sacolés destinados à sua embalagem; foi surpreendido, como já referido, em local conhecido como ponto de venda de drogas e adotou conduta suspeita ao avistar a guarnição, dispensando a sacola que trazia consigo; estava em companhia de pessoa que, em solo policial, confirmou ter ido ao encontro do réu para solicitar-lhe entorpecentes; estava em poder de dinheiro em notas trocadas, cuja origem lícita não comprovou; aos policiais, informalmente, confessou a traficância. Salienta-se, por fim, a ausência de demonstração inequívoca da condição do réu de usuário de drogas: ainda que a mãe do réu a tenha apontado, Elias - conhecido do réu e com quem ele estava quando da abordagem - nada declinou a respeito. De todo modo, a circunstância não é incompatível com a traficância, sendo, pelo contrário, muito comum o envolvimento de consumidores de drogas com o tráfico.

Comprovada a autoria do crime de tráfico, assinala-se que a materialidade igualmente está bem demonstrada: o réu, abordado e surpreendido na posse de drogas

destinadas ao tráfico, foi preso em flagrante delito (Auto de Prisão em Flagrante Delito a fls. 01) e a respeito da conduta foi lavrado Boletim de Ocorrência (fls. 22/25). Registrou-se a apreensão, no bolso do réu, de R\$ 100,00 em dinheiro (comprovante de depósito judicial a fls. 60); no bolso do réu, de três lâminas da marca Lord; no bolso do réu, de um invólucro plástico que continha substância entorpecente; no saco de papel, de vários sacolês plásticos, e no saco de papel, de sessenta e cinco invólucros que continham substância entorpecente (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 26).

Tanto preliminarmente (Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente a fls. 28/30), como definitivamente (Laudo de Exame Químico-Toxicológico a fls. 156/158), identificou-se que a substância entorpecente, com massa líquida total de 21,98g, tratava-se, efetivamente, de cocaína.

Frente ao exposto, sendo incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal e devendo o réu ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, passo à dosimetria das penas com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

O réu não registra antecedentes desabonadores (Folha de Antecedentes a fls. 99/100, Certidão Estadual de Distribuições Criminais a fls. 101/102 e Certidão da Vara da Infância a fls. 103). Todavia, estava em poder de crack, substância entorpecente cujos efeitos deletérios sobre o organismo humano são mais drásticos que o de outras substâncias de uso proscrito no Brasil, sendo mais grave, portanto, a potencialidade lesiva de sua conduta, porque agravado o risco à saúde pública.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal e àquelas enumeradas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, à vista da preponderância do caráter de maior lesividade da conduta, fixo as penas-base um sexto acima dos mínimos legais, ou seja, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Tem incidência na hipótese a atenuante da confissão, conquanto informal e retratada posteriormente (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd'), pois constituiu elemento de convicção (STJ, Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).

Também se faz presente a circunstância atenuante da menoridade relativa ao tempo dos fatos (Código Penal, art. 65, inc. I), pois o réu era comprovadamente menor de vinte e um anos ao tempo dos fatos (documento de identidade a fls. 15).

Ambas as circunstâncias implicam na diminuição das penas de um sexto, as quais são conduzidas aos mínimos legais, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ante a impossibilidade de que atenuantes reduzam as penas aquém de sua cominação abstrata mínima (STJ, Súmula 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Não há agravantes a considerar.

Como já referido, o réu é primário e não registra antecedentes desabonadores, sequer na órbita da justiça infracional, do que não se infere que se dedica a atividades criminosas com habitualidade, não havendo evidências, outrossim, de seu envolvimento com organizações criminosas. Ademais, os policiais militares inquiridos não conheciam o réu anteriormente e ele foi abordado circunstancialmente e não por força da existência de denúncias a respeito de eventuais condutas criminosas, disso não se inferindo que sua atividade já fosse do conhecimento de terceiros.

Deve incidir a causa especial de diminuição de penas preconizada na Lei nº

11.343/06, art. 33, § 4º, a importar na redução das penas de dois terços, a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da vedação constante da parte final do § 4º do art. 33 Lei nº 11.343/06, e suspensão pela Resolução nº 5, de 16/02/2012, do Senado Federal, a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos constante do mesmo dispositivo, inexiste óbice legal à substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade, a qual não suplanta quatro anos.

Atendidos os requisitos dos incisos I a III do art. 44 do Código Penal, de acordo com a parte final do § 2º do mesmo dispositivo legal substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, i) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social e sede nesta Cidade, a critério do Juízo sucessivo da Execução (Código Penal, art. 45, § 1º), e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, igualmente a critério do Juízo sucessivo da Execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo prazo desta última (Código Penal, art. 46, §§ 1º a 4º).

A respeito da fixação do regime inicial de cumprimento de pena para a hipótese de conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade (Código Penal, art. 44, § 4º) observa-se que o STJ, ao julgar a Questão de Ordem na Pet. 11.796-DF, afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 600), na sessão de 23/11/2016 firmou a tese de que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 29/11/2016).

Também a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (denominado Pacote Anticrime), incluiu o § 5º no art. 112 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata da progressão de regimes durante a execução das penas privativas de liberdade, o qual passou a dispor que “não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

À vista do exposto, a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser feita com base nas normas gerais estabelecidas no Código Penal (e não se olvidando do quanto determinado no Habeas Corpus nº 596.603, Rel. o Ministro Rogério Schietti Cruz), razões pelas quais, atendidos os pressupostos legais, fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena para a hipótese de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (Código Penal, art. 33, § 2º, 'c').

Inexistentes informes precisos sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60, e Lei nº 11.343/06, art. 43), o valor unitário do dia-multa deverá corresponder ao mínimo legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, incidente atualização monetária desde essa ocasião de acordo com os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Não há ensejo à fixação de valor mínimo de indenização (a despeito da previsão do Código de Processo Penal, art. 387, inc. IV) por ser a saúde pública a objetividade jurídica do tipo penal em questão.

É caso de decretar-se a perda do dinheiro apreendido em poder do réu, que não se demonstrou não seja produto do narcotráfico. A perda é efeito automático da sentença condenatória (Código Penal, art. 91, inc. II, 'b', e Lei nº 11.343/06, art. 63, inc. I).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Jhonatas Luiz da Silva Pereira à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em i) prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser paga a entidade pública ou privada com destinação social e sede nesta Cidade, e ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da condenação, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; condeno-o, igualmente, à pena pecuniária de 166 dias-multa, com cálculo da unidade destes no piso legal, por incursão no art. 33, caput, c.c. o respectivo § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º).

Em face da extensão da pena imposta, regime de cumprimento aplicado e substituição operada, faculto a permanência do réu em liberdade.

Ao trânsito em julgado: i) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; ii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (para os fins da Constituição Federal, art. 15, inc. III); iii) oficie-se à Senad, encaminhando-lhe informação sobre o valor declarado perdido em favor da União (Lei nº 11.343/06, art. 63, §4º), objeto do depósito de fls. 60.

Publique-se. Intimem-se.

Taubaté, 21 de janeiro de 2022.

(somente nesta data em razão da interrupção do exercício de atividades jurisdicionais para tratamento de saúde)

Cláudia Calles Novellino Ballesterro
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA